

Karteikarte 1 – Einführung in die Prinzipien der Mediation



Aus dem maßgebenden *Bezugsrahmen (KK 0-Br)* der modernen Mediation und seinen daraus sich ergebenden *Grundannahmen (KK 1-Ga)* darüber, was Mediation „ist“ und leisten „möchte“, ergeben sich bestimmte *Prinzipien*. Grundsätze, an denen sich nicht nur die Qualität orientiert, sondern sich auch die Ethik der Mediation praktisch zeigen kann. Es handelt sich um die Eckpfeiler, auf denen jede Mediationschule, jeder Mediationsstil (*KK 11-Mst*) und letztlich jeder Mediator und jede Mediatorin in der Praxis aufbauen.

Überblick über die Prinzipien (Grundsätze)

1. Strukturiertheit des Verfahrens (KK 02-Pr 2, KK 10-Ph)

Nach § 1 Abs. 1 MediationsG ist das Mediationsverfahren ein strukturiertes Verfahren.

2. Eigenverantwortlichkeit aller Beteiligten (KK 02-Pr 3-6, 11, 12)

Eigenverantwortlichkeit ist nach dem hier vertretenen Verständnis der über allem stehende Grundsatz – das *Leitmotiv mediativer Konfliktbearbeitung*. Geregelt ist der Grundsatz gesetzlich in § 1 Abs. 1 MediationsG, allerdings lediglich für die Parteien. Aus dem Eigenverantwortlichkeitsprinzip erwachsen weitere Grundsätze und Fragestellungen.

☞ **Konsequenzen des Eigenverantwortlichkeitsprinzips**

- Eigenverantwortlichkeitsgrundsatz, § 1 Abs. 1 MediationsG, (KK 02-Pr 3)
- Eigenverantwortlichkeit und Freiwilligkeit, § 1 Abs. 1 MediationsG, (KK 02-Pr 4)
- Gewaltfreiheit der Mediation (KK 02-Pr 5)
- Informiertheit der Beteiligten (KK 02-Pr 6)
- Rolle und Aufgabe des Mediators (KK 02-Pr 11)
- Aktive Mitwirkung durch den Mediator (KK 02-Pr 12)

3. Neutralität des Mediators (KK 02-Pr 7)

Nach § 1 Abs. 2 MediationsG ist der Mediator eine neutrale Person. Dies stellt gewissermaßen eine Ergänzung zum Eigenverantwortlichkeitsgrundsatz dar, weist aber gleichwohl einen eigenständigen Regelungsgehalt auf.

4. Unabhängigkeit des Mediators (KK 02-Pr 8)

Nach § 1 Abs. 2 MediationsG ist der Mediator eine unabhängige Person.

5. Allparteilichkeit des Mediators (KK 02-Pr 9)

Nach § 2 Abs. 3 S. 1 MediationsG ist der Mediator allen Parteien gleichermaßen verpflichtet.

6. Vertraulichkeit des Verfahrens (KK 9-V)

Nach § 1 Abs. 1 MediationsG ist das Mediationsverfahren ein vertrauliches Verfahren.



Vertraulichkeit § 1 Abs. 1 MediationsG

Vertraulichkeit gilt neben der Eigenverantwortlichkeit als das höchste Gut, das für die erfolgreiche Bearbeitung der Konfliktsituation vonnöten ist (KK 9-V). Daraus erwachsen eine Reihe an Fragen und Problemen für die praktische Mediation.

1. Nichtöffentliches Verfahren

Anders als ein Gerichtsverfahren ist das Mediationsverfahren nicht öffentlich. Aber es kann – ebenso wie bei jenem – zu Ausnahmen kommen. Bedeutsam scheint, dass der deutsche Gesetzgeber die Mediation mithilfe des Vertraulichkeitsgrundsatzes *definiert*, obschon das nach der zugrundeliegenden Richtlinie nicht erforderlich war.

2. Geheimhaltungspflichten der Beteiligten

Vertraulichkeit bedeutet, dass die Inhalte einer Mediation geheim zu halten sind, was einerseits urheberrechtliche Gründe – Ideenschutz, etc. –, andererseits prozessrechtliche Gründe hat – die Inhalte dürfen nicht in einem weiteren Gerichtsverfahren verwendet werden.

3. Verwertungsverbote

Der Vertraulichkeitsgrundsatz hat zur Folge, dass bestimmte Inhalte in einem anschließenden Gerichtsverfahren nicht verwertet werden dürfen, auch wenn sie (gerichts-)bekannt geworden sind.

4. Sekundärpflichten

Aus Verstößen gegen den Vertraulichkeitsgrundsatz und entsprechenden konkretisierenden Absprachen, kann sich eine Pflicht zum (pauschalierten) Schadensersatz ergeben.

Strukturen

1. Organisationsrahmen (KK 45-Va)

- Termine, Ort und Zeit
- Pausen und Verpflegung etc.

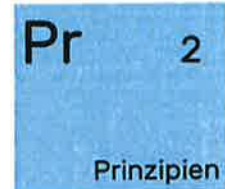
2. Verfahrensstrukturen (KK 02-Pr 2, Ph)

- Medianten aufs Gleis setzen (Phase 1)
- Medianten in Bewegung setzen (Phasen 2-4)
- Medianten absetzen (Phase 5)

3. Methoden

- Mediationsstil (KK 11-Mst)
- Mediationsfelder (KK 13-Fe)
- Interventionen (KK 15-I)

Karteikarte 2 – Strukturiertheit des Verfahrens, § 1 Abs. 1 MediationsG



Die Strukturiertheit des Verfahrens ist nicht nur eine *gesetzliche Anforderung* (§ 1 Abs. 1 MediationsG), sondern wurde bereits vor Erlass dieses Gesetzes (2012) als erfolgsnotwendige Voraussetzung angesehen – zumindest in der westeuropäisch geprägten Modernen Mediation. Ohne Struktur geht in der Konfliktbearbeitung gar nichts, zu viel Struktur allerdings erstickt jede Klärungsarbeit im Klein-Klein des Konflikts.

Gesetzliches Verständnis

Struktur gewinnt das Mediationsverfahren bereits dann, wenn es *(bestimmten) Regeln folgt, also einen vom Mediator geleiteten und erkennbar geordneten Gesprächsprozess darstellt.*

- Einerseits sind sie *im MediationsG als Pflichten* (des Mediators) *festgeschrieben* und dort den einzelnen Phasen zugewiesen,
- andererseits sind sie nicht gesetzlich fixiert, aber abhängig
 - vom *Mediationsfeld*, also Mediation in Familienstreitigkeiten, Wirtschaftsorganisationen, bei Umweltvorhaben oder in der Schule etwa (dazu KK 13 MED Fe) und
 - von der *Form der Mediation* (dazu KK 12 MED Fo) und
 - vom *Mediationsstil* (siehe KK 11 MED st).

Die Struktur ergibt sich damit aus einem normierten und einem variablen, individuellen Regelwerk.



Phasenorientierte Strukturelemente

Der Gesetzgeber hat den Mediationsphasen bestimmte Strukturelemente zugeordnet. Auch wenn er damit das Phasenmodell „an-erkennt“, ist dieses jedoch für die Strukturiertheit keine Bedingung oder die einzige Möglichkeit, Mediation in der Zeit durchzuführen.

Phase 1 - Vorbereitung	- Offenbarung und Informierung • zur Unabhängigkeit und Neutralität, § 3 Abs. 1, sowie • seiner Ausbildung und Erfahrung auf dem Mediationsgebiet, § 3 Abs. 5. und • seiner Verschwiegenheitspflicht, § 4 Abs. 4. - Vergewisserungen • zur Freiwilligkeit, § 2 Abs. 2 Hs. 2 sowie • zum Mediationsverständnis, § 2 Abs. 2 Hs 1
Phase 2 - Auftragsklärung (inkl. Mediatorver- trag)	Keine Strukturvorgaben (regelmäßig v.a. durch Visualisierungen, Aufstellungen etc. strukturiert)
Phase 3 - Problemdarstellung (Positionen)	
Phase 4 - Konflikterhellung (Interessenklärung)	
Phase 5 - Lösungsansätze	
Phase 6 - Abschlussvereinba- rung	Hinwirkungen • darauf, dass die Parteien die AV <i>in Kenntnis der Sachlage treffen und ihren Inhalt verstehen</i>, § 2 Abs. 6 S. 1, und • ggf. darauf hinweisen, dass eine Überprüfung durch externe Berater (RA!) bei Bedarf möglich ist, § 2 Abs. 6 S. 2.

Karteikarte 3- Eigenverantwortlichkeit, § 1 Abs. 1 MediationsG



Alle Beteiligten eines Mediationsprozesses agieren *eigenverantwortlich*. Das gilt für den Mediator sowie für die Medianten. Dieser Grundsatz ergibt sich aus § 1 Abs. 1 MediationsG. Dieses Prinzip trägt z.B. die Zurückhaltung des Mediators bei der Lösungssuche - er unterstützt die Parteien in ihren Verhandlungsbemühungen, übernimmt aber grundsätzlich keine Verantwortung für die Inhalte.

 Kracht in Haft/Schlieffen, HdB Mediation, 2016, § 13 - Rolle und Aufgabe des Mediators; Hagel in Klowait/Gläßer, MediationsG. Kommentar, 2015, § 1, Rn. 15 ff

Wirkung für die Medianten

1. Das „Ob“ der Durchführung der Mediation

Die Eigenverantwortlichkeit der Parteien (*Parteiautonomie*) führt dazu, dass sie darüber entscheiden,

- ob und wann sie eine Mediation beginnen und beenden (str., KK 2-Pr 4),
- wer sie als Mediator unterstützt und
- (zu einem großen Teil auch!) wie das Verfahren verläuft.

Aus dem Prinzip der Eigenverantwortlichkeit entspringt das der Freiwilligkeit (KK 2 -Pr 4).

Treffen die Medianten Absprachen dazu, wie das Verfahren ausgestaltet werden soll, übernimmt der Mediator die Verantwortung dafür, dass das Verfahren dergestalt abläuft. Lediglich, wenn die Medianten keine besonderen Verfahrensvorstellung äußern, übernimmt der Mediator die Gesamtverantwortung.

2. Hinsichtlich der Inhalte des Mediationsverfahrens

Die Medianten bestimmen, was verhandelt wird, welche Themen bearbeitet werden und welche Vereinbarungen Eingang in eine Abschlussvereinbarung finden. Zudem geht aus § 1 Abs. 1 MediationsG hervor, dass *kein Abschlusszwang* besteht („die Parteien...streben eine Einigung an“).

3. Einbeziehung Vierter

Die *Parteiautonomie* führt auch dazu, dass es den Medianten obliegt, wer neben ihnen zu den Mediationsverhandlungen eingeladen wird. Der Mediator kann nicht erzwingen, dass weitere Personen hinzugezogen werden, vgl. § 2 Abs. 4 MediationsG.

4. Eigenverantwortlichkeit im Kontext von Organisationen

In der Wirtschafts- und Arbeitswelt kommt es nicht nur auf den Willen zum Zeitpunkt des Konfliktes an. Aus dem Arbeitsvertrag oder sonstigen Vertragsumständen lässt sich (konkulent) ein entsprechender Mediationswille bzw. eine generelle Durchführungsbereitschaft herausfiltern (KK 2 -Pr 5).



Wirkung für den Mediator

Auch der Mediator agiert eigenverantwortlich. Er muss das Verfahren nicht durchführen, den Mediatorenvertrag unterzeichnet auch er freiwillig und eigenverantwortlich.

Damit übernimmt er allerdings verschiedene Pflichten, die im Folgenden seinen eigenverantwortlichen Bereich konfigurieren und konkretisieren.

- Zunächst übernimmt er die Verfahrensherrschaft, die er allerdings ausschließlich in Absprache mit den Medianten ausführen kann.
- Er kann lediglich eingeschränkt dafür sorgen, ob alle Konfliktbetroffenen auch Mediationsbeteiligte werden. Hier gelten, solange das Verfahren läuft(!), die Grenzen von § 2 Abs. 4 MediationsG - nur mit Zustimmung aller Medianten!
- Sein Entscheidungsraum, das Verfahren überhaupt weiter zu führen, ist an den Maßstäben von § 2 Abs. 5 S. 2 MediationsG zu messen.

Spannungsfeld

Zwischen den Eigenverantwortlichkeiten der Medianten und des Mediators besteht ein Spannungsfeld hinsichtlich der **Art und Weise von Hilfs- und Unterstützungsleistungen**. Es entzündet sich an der **Frage, inwieweit der Dritte Lösungsvorschläge unterbreiten darf bzw. soll**.

Denn der Mediator hat im Grundsatz eine andere Rolle als ein Richter oder Schlichter. Weder gehört zu seinen Aufgaben, ein Urteil/eine Entscheidung verbindlich zu fällen, noch, dass er einen Entscheidungsvorschlag unterbreiten muss.

Ist ein Mediator im Grundsatz auch nicht dafür engagiert, in der Sache Vorschläge zu unterbreiten, heißt das auch, dass er keine Vorschläge unterbreiten darf? Würde er seinen Status als Mediator verlieren, wenn er in Absprache oder auf Nachfrage Vorschläge unterbreitet?

Leitlinie für die Antwort ist die Eigenverantwortlichkeit der Medianten: Haben sie genügend Freiraum, über etwaige Ideen und Vorschläge ohne Druck und frei von Zwang nachzudenken? Können Sie die Ideen, Anregungen und auch Vorschläge derart verarbeiten, dass sie sich diese zu eigen machen?

Zum Ganzen KK 02-Pr 12.

Karteikarte 4 – Eigenverantwortlichkeit und Freiwilligkeit



Die Eigenverantwortlichkeit der Beteiligten führt zu dem Grundsatz, dass die Beteiligten freiwillig an dem Verfahren teilnehmen. Dies gilt – obschon nur für die Konfliktparteien in § 1 Abs. 1 MediationsG geregelt – für alle Beteiligten, einschließlich des Mediators.

📖 Dazu Hagel in Klowait/Gläßer, MediationsG. Kommentar 2012, § 1, Rn. 14 ff.; Wagner/Eidenmüller, Mediationsrecht, 2015, Kap. 1, Rn. 15 ff.; Greger/Unberath, MediationsG. Kommentar, § 1, Rn. 29 ff.; Dendorfer/Krebs KD 2012, 212 ff.

Freiwilligkeit, § 1 Abs. 1

§ 1 Abs. 1 MediationsG verlangt, dass *die Parteien freiwillig die Beilegung ihres Konflikts anstreben*.

1. „freiwillig“ + „die Beilegung ihres Konflikts anstreben“ (str.)

Das Prinzip markiert die Differenz zur staatlichen Gerichtsbarkeit. Es ist dann erfüllt, wenn die Beteiligten selbst und ohne äußeren Zwang darüber entscheiden können, was sie tun und nicht tun werden.

Aber worauf muss sich die Freiwilligkeit beziehen?

Eine Ansicht: Freiwilligkeit ist ein grundlegendes Prinzip, weshalb es sich über das gesamte Verfahren der Mediation erstrecken muss. Das bedeutet, dass die Parteien selbst und ohne äußeren Zwang darüber entscheiden, *ob überhaupt ein Mediationsverfahren eingeleitet wird, wann es durchgeführt werden soll und wann es beendet wird*. Daraus ergibt sich indessen auch, dass es keinen Anspruch darauf gibt, Mediation frei von (innerem) Druck durchzuführen.

Andere Ansicht: Die europäische Mediationsrichtlinie sowie das MediationsG beziehen Freiwilligkeit ausschl. auf Beendigung, nicht auf Beginn. Diese Ansicht hat keine Schwierigkeiten damit, zwangsweise Mediation anzuordnen.

📖 Siehe Ponschab ZKM 2014, 125

2. Ausprägungen

- Nach § 2 Abs. 5 S. 1 kann jede Partei das Verfahren jederzeit ohne Begründung beenden.
- Nach § 2 Abs. 2 muss sich der Mediator ausdrücklich vergewissern, dass die Parteien freiwillig teilnehmen. *Bedeutsam* ist allerdings, dass die *Entscheidung zur Mediation nicht zum Wesenskern* von Mediation gehört, anders als die Entscheidung über die Beendigung bzw. zur Akzeptanz der Inhalte der Abschlussvereinbarung.
- Eine Pflicht zur Teilnahme kann mitunter sinnvoll sein und wird i.R.d. § 278 Abs. 5 ZPO für den Bereich des Güterichterverfahrens zumindest ermöglicht. Das Bekenntnis zur Freiwilligkeit der Mediation verdeutlicht zumindest, dass der Gesetzgeber der Verführung widerstehen möchte, Mediation als Mittel zum Zweck (der Justizentlastung) einzusetzen, mag der Entlastungseffekt auch erwünscht sein.

Kontext: (Wirtschafts-) Organisationen

1. Reaktive Mediationsvereinbarung im Zuge eines Konflikts

Den (arbeits-)vertraglich gebundenen Parteien ist es unbenommen, im Konfliktfalle zu vereinbaren, eine Mediation durchzuführen. Das entspricht ihrer Privat- und Vertragsautonomie, auch i.R.v. bestehenden Verträgen sowie Arbeitsverträgen.



Das trifft für das Verhältnis von AG und AN ebenso zu wie für Unternehmer untereinander, (das ist anders für Schiedsvereinbarungen, vgl. §§ 4, 101 Abs. 3 ArbGG)

2. Präventive Mediationsabreden in Arbeitsverträgen

Werden im Arbeitsvertrag **individuelle oder standardisierte Mediationsklauseln** vereinbart, werden diese – mangels Kontrahierungszwanges – freiwillig vereinbart, so dass auch das Mediationsverfahren freiwillig (wenn auch nicht druckfrei!) begonnen wird. Das entspricht dem Freiwilligkeitsprinzip. siehe dazu auch KK 6-Vg

3. Reaktive Anordnung durch Vorgesetzte

Das Unternehmen bzw. die vorgesetzte Führungskraft kann auf der Grundlage des **arbeitsvertraglichen Direktionsrechts, § 103 GewO, bzw. Weisungsrechts, § 106 GewO**, die Teilnahme an einer Mediation verordnen. Damit ist der Arbeitnehmer **zur Aufnahme der Mediationsverhandlungen verpflichtet**. Gleichwohl kann der AN die Mediation entsprechend § 2 Abs. 5 S. 2 MediationsG **jederzeit beenden**.

wichtiger Hinweis

Die Pflicht zur Aufnahme besteht allerdings nicht, wenn die Mediation Themen behandeln wird oder soll, die nicht vom Direktions- und Weisungsrecht umfasst sind (Lohnhöhe, Umfang der Arbeitsleistung, nicht Qualität!). Häufiger Anlass innerbetrieblicher Mediationen sind konfliktäre Teamkommunikationen, so dass Mediation häufig Teamentwicklung ermöglicht oder fördern soll. Das ist mediationstauglich.

4. Präventive betriebs- bzw. kollektivrechtliche Regelungen

Möchten **mitbestimmungspflichtige Unternehmen** ihr **Systemdesign** (KK 44-Sd) **und Konflikt-managementsystem** (KK 43-Kms) weiterentwickeln und Mediation verbindlich für innerbetriebliche Konflikte vereinbaren, sind bestimmte Aspekte zu beachten:

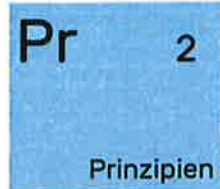
- Da damit das **Ordnungsverhalten der Betriebsangehörigen** geregelt wird, handelt es sich um eine mitbestimmungspflichtige Angelegenheit i.S.d. § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG.
- Die Teilnahme von **BR-Mitgliedern an Mediationen unterliegt nicht dem Direktions- und Weisungsrecht des Arbeitgebers**.

Deshalb **bedarf es Betriebsvereinbarungen** für alle AN zur verbindlichen Einführung von Mediationsverfahren zur Konfliktregelung. Besteht eine wirksame Betriebsvereinbarung, können AN lediglich das Recht zur jederzeitigen Beendigung nach § 2 Abs. 2 MediationsG beanspruchen.

weitere Konstellationen

- **Arbeitsgerichtlicher Vorschlag i.S.d. § 54 a ArbGG:** Sollte das Gericht einen Vorschlag zur Durchführung einer Mediation unterbreiten, muss dem keineswegs gefolgt werden. Eine verbindliche Anordnung durch das Gericht ist nicht möglich.
- **Sonstige Gerichtsvorschläge, §§ 278 a ZPO, 36 a FamFG:** Auch diese gerichtlichen Vorschläge stehen grundsätzlich nicht im Widerspruch zum Freiwilligkeitsprinzip.
- **Einseitige Anordnungen:** Im Wege einer letztwilligen Verfügung, im Rahmen einer Auslobung, aber auch in Vereinssatzungen und Gemeinschaftsordnungen oder in Gesellschaftsverträgen können grundsätzlich wirksame Anordnungen zur Durchführung eines Mediationsverfahrens getroffen werden.

Karteikarte 7 – Prinzipielle Anforderungen an den ausgebildeten Mediator



Ein Dritter im Konflikt hilft den streitenden Konfliktparteien nur, wenn er **neutral und für beide Seiten gleichermaßen zur Verfügung** steht. Andernfalls koaliert er mit einer Seite und stellt de facto eine (soziale) Eskalation des Konflikts dar. Das (deutsche) Mediationsgesetz verlangt deshalb vom Mediator, dass er **neutral, unabhängig und allparteilich** ist.

Es sind **nicht konstitutive Merkmale für die Mediation im juristischen Sinne**: Das heißt, es handelt sich auch um eine Mediation i.S.d. Gesetzes, wenn der Mediator nicht neutral und abhängig vermittelt. Das ist anders z.B. bei den Merkmalen der Strukturiertheit und Eigenverantwortlichkeit, § 1 Abs. 1 MediationsG.

Greger in HdB Mediation 2016, § 27; Unberath, H.: Eckpunkte der rechtlichen Gestaltung, ZKM 2012, S. 12 - 16.

Gesetzliche Regelungen

- **§ 1 Abs. 1 MediationsG: Der Mediator ist eine „unabhängige und neutrale Person“**,
- **nach § 2 Abs. 3 MediationsG ist er „allen Parteien gleichermaßen verpflichtet“**,
- **§ 3 Abs. 1 MediationsG bestimmt, dass er alle Umstände offenzulegen hat, „die seine Unabhängigkeit und Neutralität beeinträchtigen können“.**

Begriffsklärungen

1. Neutralität und Unabhängigkeit

Worauf beziehen sich diese beiden Begriffe? Beschreiben Sie nicht dasselbe?

Zum einen wäre es möglich, dass sich der Begriff der Unabhängigkeit auf die Person des Mediators bezieht (Er muss unabhängig von den Parteien *sein.*), während sich der Begriff der Neutralität auf sein Verhalten während der Mediation bezieht (Er muss sich neutral *verhalten.*).

Andererseits – und im Einklang mit dem Europäischen Verhaltenskodex für Mediatoren – lässt sich aus §§ 1 Abs. 1 und 3 Abs. 1 MediationsG entnehmen, dass Unabhängigkeit die Bindungsfreiheit der Person *vor Beginn der Mediation* meint, während Neutralität *die Stellung und das Vorgehen während des Verfahrens* bezeichnet. Unabhängig ist der Mediator, wenn er nicht in irgendeiner Weise an eine der Parteien gebunden ist, sei es finanziell, juristisch oder familiär. Neutralität beschreibt sodann seine faire Vorgehensweise im Verfahren, wie er sich den Parteien gegenüber zu verhalten hat und worauf er zu achten hat.

- Unabhängigkeit des Mediators besteht, wenn die Beziehung zu den Parteien vor und während des Verfahrens frei von Bindungen ist, die einen fairen (und neutralen!) Umgang im Verfahren beeinträchtigen können(!). Näheres dazu KK 02-Pr 8.
- Neutralität besteht, wenn der Mediator als unparteilicher Verhandlungsleiter im Mediationsverfahren agieren kann bzw. agiert. Er kann neutral agieren, wenn er frei von gefährdenden Bindungen ist (siehe Unabhängigkeit KK 02-Pr 8) und mit gefährdenden Einflüssen während des Verfahrens „bewusst und neutralitätsangemessen“ umgeht.

Einzelheiten dazu KK 02-Pr 9.



2. Allparteilichkeit

Nach § 2 Abs. 3 MediationsG ist der Mediator „allen Parteien gleichermaßen verpflichtet“. Dies verpflichtet ihn, bei aller gesetzlichen und sprachlichen Unbestimmtheit dieses Begriffes, zu einem

- fairen,
- zugewandten und
- aktiv förderlichen Verhalten,

um eine Lösung des Konflikts zu ermöglichen.

Einzelheiten siehe KK 02-Pr 10.

Karteikarte 8 – Unabhängigkeit des Mediators



§ 1 Abs. 2 MediationsG verlangt, dass der Mediator eine „unabhängige und neutrale Person“ ist. Nach § 3 Abs. 1 MediationsG muss er alle Umstände offenlegen, „die seine Unabhängigkeit und Neutralität beeinträchtigen können“.

Bei Vorliegen potenziell beeinträchtigender Umstände darf der Mediator nur mit ausdrücklichem Einverständnis der Parteien als Mediator weiter agieren, weshalb er diese Umstände zu offenbaren hat.

Der Umstand, dass der Mediator bereits mit der Sache (vor-)befasst war, führt sogar – wenn auch in dieser Weite völlig unangemessen – zu einem absoluten Tätigkeitsverbot.

Die Unabhängigkeit und Neutralität werden auch juristisch *durch verschiedene Sanktionen gesichert*. Dazu KK 05-Rg sowie KK 07-Rm.

Greger in Haft/Schlieffen, HdB Mediation, § 27; Hagel, U. Kommentierung zu § 1, Rn. 22 ff. in Klowait/Gläßer, MediationsG, Baden Baden 2014.

Definition und Erläuterungen

Unabhängigkeit des Mediators besteht, wenn die Beziehung zu den Parteien vor und während des Verfahrens frei von solchen Bindungen ist, die einen fairen (und neutralen!) Umgang im Verfahren beeinträchtigen können.

Die Bindungen, welche den Mediator mit einer der Konfliktparteien verbinden, können wirtschaftlicher, freundschaftlicher, familiärer oder juristischer Natur sein. Mittelbare Verbindungen reichen ebenso aus wie Verbindungen zu juristischen Personen, die ihrerseits solchen Verbindungen unterliegen.

Problem:

Derlei beeinträchtigende Bindungen können auch be- bzw. entstehen, wenn sie allein in der Person des Mediators begründet sind und/oder seinen prägenden Erfahrungen entstammen. (z.B. Geschlechtszugehörigkeit, Hautfarbe, sexuelle Orientierung, politische Einstellung etc.). Auch diese *können* dazu geeignet sein, den Medianten nicht unvoreingenommen gegenüberzutreten. Und das würde nach dem Wortlaut des Gesetzes auch ausreichen, da die Beeinträchtigung der Unabhängigkeit nicht vorliegen muss, sondern kann. Die *Möglichkeit der Beeinträchtigung der Unabhängigkeit* ist ausreichend, um eine Offenbarungspflicht zu begründen.

Andererseits kann es nicht richtig und vom Gesetz gewollt sein, dass der Mediator zunächst seine prägenden Erfahrungen mit Müttern und Vätern, mit dem anderen Geschlecht, mit Frauen, Männern, Beamten etc. darlegt, seine sexuelle Orientierung ebenso wie seine modischen Aversionen mitteilt. All jenes, was Gegenstand von Vorurteilen und damit von möglichen Beeinträchtigungen einer Unabhängigkeit ist, wäre darzulegen.

Aber wo ist die Grenze?

Das **Gesetz geht aber nicht per se von einer Welt des Misstrauens** aus, sondern möchte die **Widersprüchlichkeit und Vieldeutigkeit der Welt, deren Komplexität praktikabel gestalten**. Orientiert man sich an der Rechtsprechung für Richter und deren Befangenheitsthemen, so ist *aus der Sicht der Parteien bei vernünftiger Würdigung aller Umstände zu beurteilen, ob an der Unabhängigkeit des Mediators Zweifel bestünden*.

Der Mediator hat bei der Frage, was er zu offenbaren hat, emphatisch die Sicht der Parteien zur Grundlage zu nehmen und sich zu fragen, ob verständlicherweise Zweifel an seiner Unabhängigkeit aufkommen können.

Beispiele für offenbarungspflichtige Bindungen



1. Persönliche Bindungen

Persönliche Beziehungen sind offenbarungspflichtig bis zum dritten Grad der Verwandtschaft, also in jedem Falle Ehe, Verlobnis, Verwandtschaft, Schwägerschaft.

Auch eine frühere persönliche Beziehung, z.B. nach der Scheidung, sowie aktuelle Freundschaften sind anzuzeigen. Einfache Bekanntschaften begründen hingegen keine Offenbarungspflicht.

2. Rechtliche Bindungen

Eine Person, die zum Verfahrensgegenstand der Mediation eine rechtliche Bindung innehat, ist nicht ohne ausdrückliche Zustimmung der Medianten als Mediator zulässig. Das trifft für Testamentsvollstrecker, Insolvenzverwalter und Aufsichtsräte zu.

Gesetzliche Vertreter – z.B. Betreuer – können nicht Mediatoren in Fällen sein, in denen die zu Vertretenden Medianten sind. Hier fehlt es bereits an der Eigenschaft eines Drittbeteiligten.

3. Mitgliedschaften

Ist eine juristische Person Mediant, muss der Mediator offenlegen, wenn er Mitglied dieser juristischen Person ist. Nicht selten ist das aber ohnehin bekannt (Gemeindemitglieder, anders bei Vereinsmitgliedschaft).

Soweit den Mediator mit einem Medianten die Mitgliedschaft in einer juristischen Person verbindet, ist das nur bei persönlichem Kontakt zueinander offenbarungspflichtig (Beide sind Mitglieder bei Greenpeace oder einer politischen Partei + pflegen direkten Kontakt zueinander...).

4. Berufliche Tätigkeiten

Anstellungen, auch vergangene, sind zu offenbaren, soweit sie nicht offensichtlich bekannt sind (so etwa bei innerbetrieblicher Mediation mit internen Mediatoren). Frühere Mandatierungen sind anzuzeigen, v.a. wenn weitere Mandate zu erwarten sind.

☞ **Beachte:** Mitunter unterliegen (frühere) Mandate und Vortätigkeiten einer Verschwiegenheitspflicht, so dass der Mediator sich vorab die Entbindung einholen muss. Erhält er sie nicht, darf er nicht mediieren!

5. Politisches und weltanschauliches Engagement

Betrifft der Konfliktgegenstand ein Gebiet, auf dem der angefragte Dritte sich intensiv engagiert, z.B. durch Lobbyarbeit, in einer Interessenvertretung etc., so hat er dies zu offenbaren. Denn dieser Umstand *kann* das Vertrauen in die Unabhängigkeit schmälern. So sind in arbeitsrechtlichen Konflikten Gewerkschaftszugehörigkeiten ebenso bedeutsam wie Mitgliedschaften in Naturschutzverbänden bei Planungskonflikten.

6. Persönliche Interessen betroffen

Sind mit dem Konflikt und Verhandlungsgegenstand persönliche Interessen des Mediators betroffen, so hat er dies zu offenbaren.

Ist der Mediator selbst Begünstigter des strittigen Testaments, ist die Offenbarungspflicht selbstverständlich, ebenso, wenn ein bestimmtes Ergebnis eine weitere Mandatierung (z.B. von der RS-Versicherung) ermöglicht oder – nicht ganz eindeutig – wenn bestimmte negative Erlebnisse die Unabhängigkeit in Frage stellen, etwa strittige Scheidungen, Vermögensverlust durch Fehlberatungen, finanzieller Ärger mit Behörden etc.



Neutralität besteht, wenn der Mediator als unparteilicher Verhandlungsleiter im Mediationsverfahren agieren kann bzw. agiert. Er kann neutral agieren, wenn er frei von gefährdenden Bindungen ist (siehe Unabhängigkeit KK 02-Pr 8) und mit gefährdenden Einflüssen während des Verfahrens „bewusst und neutralitätsangemessen“ umgeht.

Greger in Haft/Schlieffen, HdB Mediation, § 27; Hagel, U. Kommentierung zu § 1, Rn. 23 in Klowait/Gläßer, MediationsG, Baden Baden 2014.

Begriffsverständnis

1. Neutralität *und* Unabhängigkeit

Das Mediationsgesetz benennt die Unabhängigkeit und zudem noch die Neutralität als besondere, in der Person des Dritten begründete, Umstände, die für eine erfolgreiche Mediation essentiell sind.

Der Gesetzgeber selbst will die Begriffe dergestalt verstanden wissen, dass die *Unabhängigkeit sich auf die Person des Mediators bezieht und die Neutralität auf die Verfahrensgestaltung (Verhalten) im Verfahren.*

Nimmt man jedoch den Wortlaut des § 1 Abs. 2 MediationsG („Mediator ist eine unabhängige und neutrale Person“), passt dieses vom Gesetzgeber vorgeschlagene Verständnis nicht zum Wortlaut.

Deshalb ist es gut vertretbar, dass die Unabhängigkeit des Mediators vielmehr die Bindungen und Abhängigkeiten betrifft, denen der Mediator im Vorhinein unterlegen ist oder die im Laufe des Verfahrens entstehen. Die Neutralität hingegen bezieht sich auf seine Stellung und die Gestaltung des Mediationsverfahrens.

2. Neutralität

Erfasst der Begriff der Neutralität die *unparteiliche Stellung des Mediators im Verfahren*, so ist sie gewahrt, wenn

- *unabhängigkeitsgefährdende Bindungen nicht bestehen und*
- *sonstige Einflüsse eliminiert oder sonst wirkungslos bleiben,*

die die Unparteilichkeit gefährden. Derartige „sonstige Einflüsse“ sind vor allem Haltungsfragen, die nur schwer objektiviert werden können. Wichtig dabei ist es, dass der Mediator diese Einflüsse schon dann offenbart, wenn sie aus der Sicht einer Partei Zweifel an der Neutralität wecken können.

3. Neutralitätsgefährdende Einflüsse

- Spannungen zwischen Mediator und einer Partei, die heftige Gefühle beim Mediator hervorrufen (Ärger, Wut, Verletztheit, Angst oder Furcht, aber auch Liebe oder sexuelles Begehren)
- Projektionen und Skriptgefühle wie Mitleid, übertriebene Sympathie etc.
- Ungleiche und nicht zu rechtfertigende Verteilung von rechtlichen Hinweisen, Dauer von Einzelgesprächen, Zuteilung von Redezeiten etc.



Sicherstellung der Neutralität

Das Gesetz besagt in seinem Wortlaut, dass Verletzungen der Neutralität genauso zu behandeln sind wie Gefährdungen der Unabhängigkeit, also durch Anzeige/Offenbarung gegenüber den Medianten, damit diese ihr Einverständnis erklären können oder die Mediation (mit diesem Mediator) beendet wird.

Dazu E 07-Rm.

Das ist nicht sachgerecht. Die Unabhängigkeit ist infolge objektiver Umstände gefährdet, also aufgrund von objektivierbaren Bindungen und Abhängigkeiten. Anders liegt die Sache bei Neutralitätsfragen.

Dazu KK 02-Pr 8.

1. Neutralitätsgefährdungen

Die Neutralität ist zuweilen durch Einflüsse gefährdet, die nicht objektivierbar oder auch nur verhinderbar sind, aber zumeist gegensteuerbar. Eine Neutralitätsgefährdung ist z.B. denkbar durch Aufkommen von übertriebener Sympathie, Zuwendung oder auch in Folge von Frust und Ärger.

Hier zu verlangen, dass der Mediator diese (innere) Entwicklung stets gegenüber den Beteiligten offenbaren muss, um sich ihr ausdrückliches Einverständnis einzuholen, weiter mediieren zu dürfen, wäre *lebensfremd, mediationsverhindernd und uferlos förmlich*.

Hier kommt es darauf an, dass der Mediator bewusst arbeitet, sich der Neutralitätsgefährdungen bewusst wird, ggf. *eigene Supervision einholt* und dieser Entwicklung gegensteuert. Unangemessen wäre eine Sanktionierung mit Tätigkeitsverbot und Haftungsfolgen, die mit Aufkommen der (inneren) Gefühls- und Gefährdungslagen einhergeht!

2. Neutralitätsverletzungen

Führt der Mediator das Verfahren nicht neutral, agiert er vertragswidrig und macht sich Schadensersatzpflichtig. Kann der Mediator die Neutralität nicht wiedergewinnen, ist er zur Beendigung der Mediation verpflichtet - möglich nach § 5 Abs. 2 MediationsG, der es ihm erlaubt, den Vertrag aufzukündigen. Die neutralitätsbezogenen Hintergründe muss er nicht offenbaren.

Karteikarte 10 – Allparteilichkeit des Mediators



Nach § 2 Abs. 3 MediationsG ist der Mediator „allen Parteien gleichermaßen verpflichtet“. Dies verpflichtet den Dritten, bei aller gesetzlichen und sprachlichen Unbestimmtheit dieses Begriffes, zu einem fairen, zugewandten und aktiv förderlichen Verhalten, um eine Lösung des Konflikts zu ermöglichen. Aber was genau ist darunter zu verstehen?

 Gläßer, U.; Kommentierung zu § 2, in: Klowait/Gläßer, MediationsG 2014; Duss-von Werdt, Homo Mediator, 2005; Weigel: Konfliktmanagement in der Verwaltung, Berlin 2012; Tenczek, Th.: Allparteilichkeit – Anspruch und Wirklichkeit, ZKM 2016, 230 f..

Annäherungen an den Begriff der Allparteilichkeit

Die Problematik der Un-Klarheit des Begriffes „Allparteilichkeit“ bei einer Konfliktklärung spiegelt einerseits die Notwendigkeit wider, einen zugewandten und interessierten Dritten hinzuziehen zu müssen, andererseits den Wunsch der Medianten, die eigenen verworrenen Dinge selbständig herauszufinden und zu lösen.

Allparteilichkeit bestimmt Form und Inhalt vermittelnden Handelns und stellt den Persönlichkeitskern des „homo mediators“ (Duss-von Werdt) dar. Zwar gibt sie dem Mediator *keine konkreten Handlungsmöglichkeiten oder Interventionen vor*, doch alle Vermittlungsbemühungen und Interventionen wären ohne allparteiliche Wurzel der Mediation abträglich.

Allparteilichkeit verkörpert sich in einem **„absichtsarmen Engagement“**, einem Unterstützen ohne zu bedrängen, einem Anstoßen ohne zurechtweisen, einem Konfrontieren ohne zu verfolgen, eine Hilfestellung ohne zu retten.

Allparteilichkeit zeigt sich im vermittelnden Handeln des Dritten, ist aber in der Haltung des Vermittlers begründet. Allparteiliches Vermitteln ist die **Gratwanderung des Mediators**.

Komponenten der Allparteilichkeit

Allparteilich ist man nicht als Mediator, sondern man prozessiert und aktualisiert auch stetig als Mediator – man ist permanent darauf bedacht, diesen „Zustand“ beizubehalten.

1. Haltungskomponente

Mediatoren müssen sich im gesamten Verlauf stetig hinterfragen und überprüfen, selbstreflexiv und supervisorisch begleitet, ob sie jeder Partei gegenüber respektvoll, emphatisch und mit der ehrlichen und „liebvollen“ Bereitschaft gegenüberzutreten, sie unterstützen und bei der Konfliktlösung fördern.



2. Verhaltenskomponente

Die innere Haltung der Allparteilichkeit muss sich im Verhalten äußern und aktiv zum Ausdruck gebracht werden, z.B. durch eine faire und angemessene Einbindung aller in das Mediationsgespräch. Das ist insbesondere bei (Macht) ausgleichenden Maßnahmen nicht unproblematisch.

3. Wahrnehmungskomponente

Diese Komponente bezieht sich nicht auf den Mediator, sondern auf die Medianten, die letztlich die entscheidenden Personen sind, die die Allparteilichkeit „beurteilen“ können. Diese Komponente ist für den Erfolg der Mediation maßgebend.

Sie kann allerdings nicht maßgebend sein, wenn es um Haftungsfragen wegen Verletzung der Allparteilichkeit geht. Hier gilt ein objektivierter Maßstab. Mehr dazu KK 07-Rm.

Karteikarte 11 – Rolle und Aufgabe des Mediators



Aus den Grundsätzen der Mediation, die als Eckpfeiler die Grundannahmen und den Bezugsrahmen von Mediation darstellen, fließen Anforderungen an das **Rollenverständnis** und den **Aufgabenbereich** des vermittelnden Dritten. Diese seien hier zusammenfassend genannt.

 Vgl. Kracht in Haft/Schlieffen, HdB Mediation 2016, § 13; Besemer, Mediation (1995), 2003; Greger/Unberath, Mediationsgesetz, Kommentar 2012, § 2., Busch/Witte Mediation. Ein Rollenspielbuch, Schwalbach 2000, 30.

Rollenanforderungen

1. Moderator

Der Mediator hat die häufig emotional aufgeladenen Situationen zu moderieren und bei etwaigen Denkblockaden und sonstige Kommunikationshürden angemessen, d.h. vor allem allparteilich, zu intervenieren. Der Mediator **strukturiert die Kommunikation der Beteiligten**.

2. Unterstützer und Helfer, Spender von Zuversicht, Zukunftsarbeiter

Der Mediator ist kein Retter oder Verfolger (siehe E 52-Dd), sondern **eröffnet einen Gesprächsraum** für die Konfliktparteien. Im Klärungsprozess achtet er darauf, dass die Vereinbarungen realisierbar sind (Agent of Reality).

Ein wichtiges Unterstützungselement ist das **Herausarbeiten der Interessen** (Umformung der Positionen).

Je nach Verständnis, **spannt er damit die weiße Leinwand (Scharmer) auf, auf der sich die Zukunft ausbreiten** kann. Diese prinzipiell offene **Zukunft in den Blick** zu rücken, ihre abschätzbaren Konturen zu erfragen, das ist mehr als Interessenabfrage, das ist strategische **Zukunftsreflexion**.

3. Garant der Prinzipien der Mediation

- Eigenverantwortlichkeit
- Strukturiertheit
- Freiwilligkeit
- Gewaltfreiheit
- Informiertheit
- eingeschränkt: Vertraulichkeit

4. Garant für die Einhaltung der Forderungen an seine Person

- Allparteilichkeit
- Unabhängigkeit
- Neutralität

 Siehe dazu KK 02-Pr 7-9.

5. Komplexitätsarbeiter (je nach Verständnis)

Der Mediator ist als „**prozesserfahrener Nichtbeteiligter**“ in der Lage, die soziale und dynamische Komplexität des Konflikts angemessen im Blick zu behalten. Er muss sie für die Beteiligten aufhalten und schließen, je nachdem, was der Prozess erfordert (Schifferklavier).

Aufgaben

1. Aufklärungspflichten nach dem MediationsG

- § 2 Abs. 2 MediationsG bzgl. des Parteienverständnisses zu Prinzipien und Ablauf
- § 3 Abs. 1 S. 1, Abs. 5 MediationsG für Offenbarungen in eigener Sache bzw. Vorbefassungen und zur eigenen Mediationsausbildung
- § 4 Abs. 4 MediationsG zum Umfang seiner Verschwiegenheitspflicht.

2. Geeignetheitsprüfung des Konfliktfalles

Prüfung der Geeignetheit des Mediationsverfahrens für den konkreten Konflikt, da er ansonsten nicht als neutraler Dritter in diesem Konflikt vermitteln könnte.

3. Verfahren strukturieren

Sozusagen als kommunikativer Brückenbauer, vgl. § 1 Abs. 1 MediationsG.

4. Moderieren und Mediieren,

D.h. er führt die drittgestützte Verhandlung durch, um zu vermitteln, auszugleichen und zu entwickeln, KK 1 MED Ga. Bei mehreren Sitzungen sollten die Pausen-Intervalle nicht allzu lang ausgedehnt werden.

5. Vorkehrungen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit treffen

6. Ggf. Einzelgespräche mit Zustimmung der anderen Partei führen, § 2 Abs. 4 MediationsG

7. Ggf. Dritte mit Zustimmung der Parteien hinzuziehen, § 2 Abs. 4 MediationsG

8. Ggf. Dokumentation, ggf. Visualisierung

9. Ggf. die Mediation vorzeitig beenden, § 2 Abs. 5 S. 2 MediationsG